

税理士法・業務独占に関する鑑定書

税理士法における業務独占規定の解釈と無資格者による税務業務の違法性を論じた鑑定書。

【年度】－

【税目】－

【手続】鑑定書

【事件番号】－

【出典】－

【公開用編集】公開用に編集し、必要に応じて匿名化（黒塗り）しています。本文は2ページ目から始まります。

法人が税務書類を作成した場合における税理士法52条の適用可否について

—— 現行税理士法の解釈として

三木義一（立命館大学法学部教授）

博士（法学・一橋大学）

はじめに

本鑑定所見書では、1) 親会社の経理部が子会社及びグループ企業の税務申告書を一括して作成すること、2) 市販の申告書作成ソフトを使用して親会社経理部が下書きをすること、の2点につき、現行の税理士法（以下本稿では「法」と略す）からみて違法と評価しうるかについて法解釈論的に検討するものである。

一、現行税理士法の構造

わが国の現行税理士法は、税理士の業務として「他人の求めに応じ」租税に関し、「税務代理」、「税務書類の作成」、「税務相談」を行うことと規定し（法2条）、税理士でない者は、いわゆる臨税（法50条）、弁護士（法51条）、行政書士（法51条の2）、公認会計士（法附則37、38項）が一定の条件の下で例外扱いされているのを除いて、税理士業務を行うことを禁じられている。この現行税理士法による税理士業務の排他性は、職業選択の自由に対する公共の福祉（憲法22条）に基づく規制であり、租税に関する税務代理等が高度の専門性を有しており、かつ、公共性の強い業務であることに鑑み、納税者の税務代理等に対する信頼を保護し、納税者の権利が損なわれることを防止したものといえよう（なお、弁護士法における非弁護士の法律事務取扱の趣旨については最高裁大法廷昭和46年7月14日判決刑集25巻5号690頁がこの禁止規定の公益性を指摘している。また、司法書士業務については、仙台高裁平成9年5月23日判決判例時報1631号153頁が、投機業務と司法書士制度の関係につきつぎのように論じている。「登記申請の代理行為に関し、所論指摘のような規制緩和の動きがみられるかどうかはさておき、仮にこれを肯定するとしても、司法書士法一九条一項（二五条一項）、二条の立法趣旨、すなわち、公共性の強い登記業務を適正円滑に遂行せしめ、国民の登記に対する信頼性を高めるために、登記申請の代理行為を登記等の専門家としての司法書士に集中させ、原則として非司法書士が登記申請代理行為を業とすることを禁じていることについては、現在においても十分な必要性和合理性があると認められるのであって、このような規制の必要性、合理性に照らすと、司法書士法一九条一項（二五条一項）、二条が、行政書士による登記申請の代理業務を一律に禁じたとしても、これをもって直ちに職業選択の自由を保障した憲法二二条一項に違反するものでないことは明らかであり、所論は採用の限りではない。したがって、論旨は理由がない。」）従って、この税理士業務の排他性は税理士業界の独占的利益を保護するためのものでないことはいうまでもない。

その意味で、現行税理士法の規制それ自体は合理性を有しているが、他方で他の法律やドイツの税理士法と比較すると、その排他性がやや広範囲すぎるきらいがあり、その点が法形式的な解釈を躊躇する一因にもなっているように思われる。

例えば、周知のように、現行弁護士法は「報酬を得る目的」での法律事務の取扱いや斡旋を業とすることを禁じている（弁護士法72条参照。なお同規定で禁止されている行為については、非弁護士が「報酬を得る目的をもって、法律事務を取り扱い、又はこれらを斡旋することを、それぞれ業とすること」を禁止したものと解する一罪説と、非弁護士が「①報酬を得る目的をもってする法律事務の取り扱いと、②法律事務取り扱いの斡旋を業とすること」の二つの禁止したものと解する二罪説との対立があったが、前記最高裁大法廷昭和46年7月14日判決が一罪説を支持し終止符を打った）。弁護士業務の場合は、代理、仲裁等の法律事務は相手方との折衝等の労力が中心で、これを無償で遂行するのは通常経済的に不可能だからであろうし、他方で市民の法律知識の欠如に付け入って不当に高額報酬を得ることを防止すれば足りると解されたものと思われる。従って、無償であれば業として行われていても弁護士法違反にはならず、本件との関係でいえば親会社法務部の社員が子会社の法律事務を仮に行ったとしても、身内等のために法律事務を行っても無償であれば通常は特に問題とされないことになる。これに対して、税理士法は無償の税務代理等をも禁じており、その結果、上記のような場合も税理士法違反の可能性がでてくる。無償の税務代理をも禁止した理由は必ずしも明確ではないが、つぎのように解しておきたい。すなわち、税理士業務の場合は、申告納税制度のもとでは税務代理よりも税務書類の作成の方が一般納税者にとってはさしあたり重要になっている。しかも税務問題は多種多様な市場取引と連動している。そこで、無償の税務書類作成を税理士法の規制からはずすと、他の市場取引を誘引するために税務書類の作成だけを無償で請け負うことが可能になり、その結果、納税者が税務専門家に関与してもらう途を実質的に閉ざしてしまう可能性があるからであろう。このような意味で、納税者が非専門家による税務書類の作成によって不利益を受けないために、あえて無償の税務代理等も禁じていると解しておきたい。

つぎに、ドイツ税理士法の規制と対比してみたい。周知のように、ドイツ税理士法は税理士以外の弁護士等にも無制限の税務援助資格を認めると共に（同法3条）、公証人や弁理士等多くの専門家にもそれぞれの職業行使との関係における一定の税務援助資格を認めている（同法4条）。その上で、無資格者による税務援助を禁止するが（同法5条）、①学術鑑定意見、②身内に対する無償の税務援助、③記帳や記録の機械処理、④一定の実務経験のある者による継続的取引の記帳や源泉税の清算・申告、を禁止から除外している。これらの行為は、確かに有資格者に限定する合理性が乏しいものといえよう。例えば、税法上の問題について研究者が学術的な観点から鑑定書をまとめた場合、そのことによって税務援助の公共性や専門性が損なわれることは一般にあり得ないからである（わが国の弁護士法は鑑定も禁止しており、その意味で学術的意見書も厳密にいうと問題になる余地が残されている）。ドイツ税理士法では身内への税務援助が規制の対象からはずれていることも注目される。これは、資格者はないものの全くの素人ではない者が親族間では他の親族から税務援助を依頼されることが少なくなく、このような親族間の無償の行為まで規制する必要はないと判断されたものと思われる。なお、ここにいう身内とは租税基本法15条にいう身内をいい、両親や兄弟姉妹、婚約者等の個人的な親戚関係をさし、親会社、子会

社等は含まれていない。

いずれにしても、ドイツ税理士法の税務援助の緩和規定と比較すると、わが国税理士法が税務代理等の税理士による排他性をやや硬直的に規定している感は否めない。

二 税理士法の規制行為の構成要件

前述のように、現行税理士法は非税理士が「他人の求めに応じ」、税務代理等の事務を「業として」行うことを禁じているが、他方で、現行法は税理士により税務代理を強制しているわけではない。つまり、非税理士であっても納税者が自分自身のために申告書等を作成する事は、申告納税制度の理念から見ても全く問題はなく、規制の対象となるのはあくまでも「他人の求めに応じて」おこなう税務事務である。そこで、まず、この「他人の求めに応じ」をどう解すべきかについて検討しておこう。

(一) 「他人の求めに応じ」

税理士法が規制している「他人の求めに応じ」た税務事務と、前述の自己のための税務事務との境界をどこで区分するかのが問題になる。ドイツ税理士法のように、「身内」のような特定者は自己と実質的に同一であり、法の明文規定がなくとも規制の対象からはずされていると解しうるのだろうか。昭和30年代の法制局長意見や国税庁長官通達等では、税理士法の規制は「個人との親族、友人など特定の関係者を除いた不特定多数の者」に対する税務援助という見解を採用し、「関連会社が事務部門を統合して…別個の法人を設立して…関連会社について税理事務を行うことは、税理士法違反とはなりません」との見解も表明されていた（特に、昭和38年5月18日付・官総6-32・国税庁長官通達）。これらの見解は、「特定」の要件を厳格に解していたものと推定はされるが、明文の根拠を欠いていること等の難点もあり、昭和40年に示された東京高裁判決（東京高裁昭和40年2月26日判決・判例タイムズ174号167頁）で基本的に否定されたといつてよい。同判決は事業協同組合の組合員に対する税務援助が税理士法違反を問われたケースであるが、つぎのように判示している。

「そもそも、税理士でない者が税理士法所定の除外事由がないのに同法第二条所定の税理士業務を行うことは、同法第五二条によって禁止されているところであり、これに違反する行為は、本件のごとく、たとえその定款が中小企業等協同組合法に基いて知事の認証を受けたもので、定款の定める目的の範囲内で同法所定の協同組合の事業としてなした行為であっても、刑法第三五条にいう『正当の業務に因り為したる行為』には該当せず、その違法性を阻却するものではないことはきわめて明らかである。尤も、昭和二六年六月二六日二六企庁第一五三一号中小企業庁通達『事業協同組合運営指針』のうちには、『事務執行の代行業業』と題して、『1 本事業は、税務、経理労務、配給等組合員がその事業の遂行上必要な事務の執行を組合が代行して行うことにより、これらの事務の執行に不馴なために組合が不利益を蒙むることのないようにしようとするものである。2 本事業を行うには、その代行事務の内容に従い税務代理士、計理士、代書人等その事務処理に明るいものをおくのが適当である。』との説明がなされているが、これが税務に関して税理士法施行前の税務代理士法および税理士法の禁止規定までも排斥する趣旨のものとはとうて

い解されないばかりか、右通達がどのような意図のもとに発せられたものであるにせよ、これが法的効力を持つものではないことはいうまでもない。そして、記録によれば、被告人は原判示のような税務書類の作成およびこれの小田原税務署への提出をなして、税理士法第二条各号所定の事務を行い、かつ、これが、前記箱根法人協同組合の組合員の依頼に応じて、特にこれに対する報酬を得ずになされたものではあるものの、同条にいう『他人の求めに応じ、（中略）左に掲げる事務を行うことを業とする』とは、反覆継続の意思をもって他人の求めに応じて同条各号所定の事務を行えば足り、その他に、その他人が不特定であることないしは多数であること、その事務を営利の目的をもって行ったことなどを必要としないものと解されるところ、被告人は右の行為を反覆継続の意思をもって他人である同協同組合の組合員の求めに応じてなしたことが明らかであるから、被告人の右行為は、これが同協同組合の定款の定める目的事業の範囲内に属するとしても税理士法第五条に違反し、かつ、違法性の具備に欠けるところがなく、同法第五十九条によって処罰を免れず、論旨はこの点において採用できない。」（傍線筆者）

この解釈は、「特定」の組合員を対象とした税務援助行為を税理士法違反であることを強調するために、不特定という要件が法律上存在しないことを強調したものであるが、現行法の条文解釈としては一応妥当な解釈と思われる。したがって、税理士法が禁じている「他人の求めに応じ」た税務事務に該当するか否かは、「特定」か「不特定」かではなく、法がその前提としている自分自身による税務事務と実質的に同視しうる特殊事情が存しているかどうかで判断され、親族であるとか、親子会社・関連会社であるとかの理由だけでは税理士法の規制の対象外にはならないと思われる。

なお、連結決算が導入されてから関連企業の財務関係は緊密度を増しているが、連結納税制度が導入されて関連会社の税務申告も親会社自身の税務申告として扱うような法整備が整わない限り、親子会社間も法人格が異なる以上単なる親子会社であるというだけでは「他人の求めに応じ」た税務事務という要件を回避することはできないと思われる。子会社、関連会社といえども親会社等とは別個の独立した法人であることには変わりはないからである。相続税の債務控除の判定に際して求償の可能性を連結決算をしている関連会社全体の状況を判断すべきと主張した原告に対し、横浜地裁平成11年4月26日判決（判例未登載）はつぎのようにそれぞれの独立性を強調している。

「原告は、K社が弁済不能の状態に陥っていたかどうかは、K社1社の帳簿価額ではなく、子会社6社を含むKグループ全体の財務状況を考慮して判断すべきである旨主張し、証拠によれば、K社及び子会社6社の比較（連結）決算報告書における債務超過額が多額であることが認められる。グループ全体の財務実績を把握する際には連結決算は有益であるが、親会社及び子会社もそれぞれが別個独立の法人であり、例えば子会社債務を親会社が常に負担すべき法的な義務があるわけではないので、K社の弁済能力の有無はK社だけについて判断すべきである。」

現行税法では、関連会社はその特殊関係により通常の第三者の場合と異なる取引を租税回避目的等で行う可能性があり、その点を税法は課税要件の認定に際して注視するとはいうものの、これらの会社が法的には別個の独立した法人であることを否定することはできないと思われる。その意味で、親会社の経理部が子会社の税務事務を代理することは、当

該行為が親会社自身の行為と同視すべき何らかの特殊事情がない限りは、「他人の求めに応じ」た税務事務の代理として税理士法の規制の対象となろう。

ただし、現行法では納税者自身が税務事務を行うことは当然視されており、法人の場合は当該法人の従業員が税務事務を行うことは問題ないとされている。すなわち、法人の経理担当の従業員は通常非税理士であるが、このような従業員が雇傭主のために税務書類の作成を業とすることは許容されていると一般に解されているが、これは当該従業員と法人との間に他人関係がないからというのではなく、「右従業員が雇傭主たる法人のためにその本来の業務活動の一翼をになう関係にあるので、あたかも法人が自ら（正確に言えば法人の業務執行者が自ら）税務書類の作成をするのと同視し得る」（東京高裁昭和40年4月12日判決・刑集20巻3号186頁。この判断は最高裁第一小法廷昭和41年3月31日判決・刑集20巻3号186頁でも支持されている）からであると考えられているのである。そうすると、親会社が経理部の従業員を子会社の経理部に出向させ、親会社と連携しながら子会社の指揮命令の下で税務事務を行った場合は、当該子会社自身による税務事務の行使といえるかどうか微妙な問題が生じる。移籍出向の場合は子会社自身の行為と評価してよいと思われるが、親会社に籍を残したままの在籍出向の場合は、これを安易に認めると下記のような雇用関係の偽装事案を誘発する恐れもあり、子会社における指揮命令が子会社自身の従業員と同様であり、かつ、勤務形態が子会社従業員と同一の場合、等のような一定の限定を付す必要がある。

なお、従業員の行為は法人自身の行為であると解されることを利用し、雇用関係を偽装するケースがあり、パートタイム的に各法人に「勤務」し、税務事務を行った者に対する税理士法違反事件で、名古屋高裁昭和48年2月27日判決（判例タイムズ297号372頁）はつぎのような判断を示している。

「関係各証人は、原審公判廷において、いずれも被告人を各企業体外の第三者としてではなく、各企業体内部の非常勤の事務員として雇傭していたものである旨供述し、被告人も非常勤かつパートタイム的勤務の事務員であったのであるから、各企業主と被告人との間には右税理士法2条にいう『他人の求めに応じ』という法律関係は生じない旨弁解しているが、前認定のように起訴に係る分においても被告人が関係した企業体は法人3件、個人6件の多数に上り勤務時間は全く不規則であり、また、被告人が勤務時間に拘束されることはなく、給料の名目で支払われる金額は勤務時間に比例するものでないものであるから、いわゆるパートタイマーの場合とは本質的に異なっていること、各企業主は、被告人が確定申告書等の税務書類作成の知識経験を有していたので、それを利用するため被告人に依頼したもので、毎月の帳簿類も右税務書類作成に必要な限度で被告人に目を通してもらったり、指導を受けたり、あるいは、整理をしてもらっていたものであることが容易に推認できる。従って、各企業主が被告人を非常勤の事務員という形式で依頼したのは、被告人に税務書類を作成してもらうという単にそれだけの目的であったと認められること、また、被告人も単にそれだけの目的のためにこれらの事務をそれぞれ行なっていたものであることが推認できる。それらを総合すると、各企業主と被告人との関係を、所論のように雇傭関係とみるのは相当でなく、税務書類の作成を主たる目的とする事務処理に関する有償の委任契約関係と解するのが相当であるから、前示各企業体と被告人との間に、右税理士法

2条の『他人の求に応じ』という法律関係が生ずることは明らかであるというべきである。…また、法人の経理担当の従業員は、非税理士であっても、雇傭主のために税務書類の作成を業とすることが許容されていると一般に理解されていることは所論のとおりであるが、これは右従業員が雇傭関係に基づき雇傭主たる法人のためにその本来の業務としてなす関係にあるので、あたかも法人自ら税務書類の作成をするのと同視しうるからであって、本件の被告人の立場を所論のような法人の経理担当の従業員と同視することはできない。」

また、会員制の社団の従業員として税務事務を行った場合も、当該社団への入会という形で税務書類の作成依頼がなされている場合は「同会の従業員たる義務に基いて行われたとしても、それは会員の税務書類作成の依頼が同会への入会という形で行われたことに基因するのであるから、被告人が他人の求に応じて税務書類を作成したということになるといわざるを得ない」のも当然であろう（前掲・東京高裁昭和40年4月12日判決）

以上のように、現行税理士法との関係では親子会社間でも独立した法人同士であり、親会社が単に子会社という理由だけで、当該子会社の税務事務を行うことは「他人の求めに応じ」た行為に該当するといわざるを得ないと思われる。

ここで、論じたことは基本的に弁護士法上も同様に解されると思われる。企業の法務部が当該企業の法律事件を処理した場合には、法務部の職員が非弁護士であっても問題にはならない。しかし、法務部が独立の組織になったり、親会社が子会社の法律問題を処理するために、親会社の法務部門を分離独立させた場合には、弁護士法違反の問題が生じると解されている（例えば、日本弁護士会調査室編『条解弁護士法・第2版』弘文堂、1996年、538頁参照）

（二）「業とする」

現行税理士法は「他人の求めに応じ」て税務事務を「業とする」ことを禁じている。この「業とする」という意味内容については、税務代理士法時代の最高裁判決が「反覆継続の意思を以て同法第一条所定の行為を為せば足りるものであって、その行為に対し報酬又は利益を得る意思あること若しくは現にこれを得た事実の存在することを必要とするものではない」と判断して以来、判例上は「無償による反復継続」でほぼ確立している（前掲・東京高裁昭和40年2月26日判決等も参照）。仮に、有償行為を規制するのが法の目的であれば、弁護士法のような規定をすべきであり、無償行為も規制せざるを得ない税務事務の特殊性を考慮すると、現行法の解釈としては正当であろう。

（三）本件設問1の判断

以上を総合すると、設問1の「親会社の経理部が子会社及びグループ企業の税務申告書を一括して作成すること」は、当該親会社の作成行為が自己の税務申告書作成行為と同視し得るような何らかの特殊事情がないのに、単に親子会社・関連会社というだけの理由や経費節減等の理由で行われた場合は、税理士法違反の問題が生じるといわざるを得ない。なお、親会社の作成するものが子会社の申告の一資料にすぎず、子会社が実質的に当該資料を点検して自らの判断に基づいて申告するものである場合は税理士法の規制の対象とは

ならないと思われるが、他方で、会計資料という名目であっても子会社が自ら判断する必要が無く、署名・押印するだけで申告書としての機能を果たすものである場合には、税理士法に反するものと解される。

（四）本件設問2の判断

以上の基本的認識の上に立って、設問2の「市販の申告書作成ソフトを使用して親会社経理部が下書きをすること」と税理士法の関係を検討したい。

コンピューターの発達により記帳や税務計算が簡易にできるようになってきている。このように簡易になってきた以上、他人の申告書を非税理士が作成しても実質上、税理士等の専門家が作成するのと同様になってきているとしたら、税理士という資格制度の存在意義そのものが問われよう。確かに、市販ソフトによる計算は簡便になってきているが、複雑な租税法上の納税者の権利を適切に行使するためには、インプットに際しての法的・専門的判断がますます重要になってきている。従って、当該ソフトがデーターの機械的な保存・集計に関するものであれば別段問題はないが、入力に際して税法上の権利に関する法的・専門家的判断を要する場合は、当該ソフトを利用して税務書類の作成を下書きすることも税理士法の規制の対象といわざるを得ない。もし、これを容認すると、前述の意味で規制している税理士法の意図は実質的に形骸化されてしまうと思われるからである。

なお、下書き等がやはり税理士法の規制の対象になることは、前述の東京高裁昭和40年4月12日判決のつぎの判示からも容易に理解されよう。

「税理士法第2条第2号にいわゆる『書類を作成する』とは、単に他人の指示するところを機械的に記述代書するような事務を含まないことはもちろんであるが、他人のために所定の要件に適合するかどうかを自ら判断して必要事項を記載し書類を完成してやるときは、署名押印はその他人がする場合であっても、これに該当するものと解すべきである。記録によれば、被告人は、原判示のように『申告書用紙に所要の事項を記載する』については、単に申告者の指示するところを機械的に記述代書したものではなく、自己の判断により所定事項を自ら記載し又は事務局員を指導してこれを記載させたうえ自己の責任においてその記載を確認したものであるから、たとえ申告者が書類の完成後これを承認して署名押印したとしても、本件書類は被告人が税理士法第2条第2号にいわゆる作成をしたものといわなければならない。」

三 連結納税制度への展望

現行税理士法の解釈として設問について検討すると上記のような結論になる。しかし、税理士会の中にはこのような条文重視的解釈に躊躇する意見も見られる。これは、現行法がドイツ税理士法と比べてもやや硬直的な規定になっていること、連結決算が導入されてグループ会社間の経理の連携性が強まってきていることを配慮したものであろう。確かに、連結決算により経理の連携性は強まり、将来的に連結納税制度が導入された場合には、当該連結納税制度の仕組み如何では親会社が子会社の分を一括して申告する方式も想定しうる。そのような場合は、親会社が子会社の経理及び税務事務を行うことは親会社自身の申告のために必要であることになり、このような場合は現行法の下でも「自己の申告と同視

しうる特殊事情」が存在することになろう。しかし、現行法の解釈として親子会社・関連会社というだけで、そのような特殊事情を肯定するのは難しいと思われる。

ただし、立法論としては連結納税制度も視野に入れて、ドイツ税理士法などをも参考にしながら、一定の親族関係者や、一定の関連企業に対する税務事務の代理等を税理士法の規制の対象から明文で除外することが望ましいと思われる。場合によっては、弁護士法同様「有償行為」に限定することも考えられてよいであろう。従って、現行税理士法の解釈としてはともかく、税理士会の運用としては上記のような社会状況を配慮して、税理士法を杓子定規的に運用するのではなく、無資格者による明白な税理士業務の遂行（最近のでは、例えば、新潟地裁平成7年3月22日・税務訴訟資料210号1287頁で有罪判決が出された司法書士による税理士業務遂行事件、等）や関係会社を利用した雇用関係の偽装や悪質な税理士回避行為についてのみ税理士法違反として運用していくのが妥当と思われる。